

1500641-64.2022.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... notícias de seu envolvimento com o narcotráfico.

No dia dos fatos, agentes policiais realizavam nova campanha velada, oportunidade em que, confirmando informações e diligências anteriores, notaram "movimentação anormal" e efetivo ato de tráfico de drogas no local, já que, na ocasião, MARCOS foi visto em frente à sua casa, entregando porções a um usuário, em nítida mercancia. Após a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500641-64.2022.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500641-64.2022.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208956/2022 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 26499258 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2208956 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DERICK LUCAS MARQUES MENDES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MARCOS VINICIUS SANTOS FRANÇA, MARCELO SILVA FRANÇA e DERICK LUCAS MARQUES MENDES, já devidamente qualificados nos autos, em decorrência da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia (fls. 148-151), no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 11:35 horas, na Avenida Amazonas, nº 1433, Vila São Paulo, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, MARCOS vulgo "Bigode", MARCELO e DERICK, em concurso de

peças caracterizadas pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, guardavam e mantinham em depósito drogas para fins de tráfico consistentes em 13 porções de maconha com massa bruta total de 14,29 gramas; 13 porções de crack com massa bruta total de 3,88 gramas; e 60 pinos de cocaína com massa bruta total de 41,59 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, MARCOS, vulgo "Bigode", estava sendo investigado pela Polícia Civil de Capão Bonito há algum tempo em razão de notícias de seu envolvimento com o narcotráfico.

No dia dos fatos, agentes policiais realizavam nova campanha velada, oportunidade em que, confirmando informações e diligências anteriores, notaram "movimentação anormal" e efetivo ato de tráfico de drogas no local, já que, na ocasião, MARCOS foi visto em frente à sua casa, entregando porções a um usuário, em nítida mercancia. Após a entrega, o réu retornou para seu imóvel. Tentada a abordagem do comprador, este imediatamente fugiu correndo da equipe policial.

Diante da fundada suspeita, os policiais ingressaram no imóvel em questão, onde surpreenderam MARCOS, MARCELO e DERICK, no mesmo cômodo, próximos às porções de maconha já descritas, que estavam sendo fracionadas e embaladas pelos réus, de modo que receberam voz de prisão em flagrante. Com a situação controlada, os agentes públicos revistaram o imóvel e encontraram as já referidas porções de cocaína dentro de um armário, e de crack, embaixo de um sofá, já fracionadas e prontas para a venda, conforme imagens às fls. 66 e 67.

Além das drogas, os policiais apreenderam R\$ 247,00 em notas de valores variados; dois telefones celulares; um caderno com anotações relacionadas ao narcotráfico; e diversos saquinhos plásticos destinados ao acondicionamento de entorpecentes (auto de exibição e apreensão às fls. 24).

Diante das informações pretéritas, das circunstâncias da ação criminosa, da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, e apreensão de instrumentos e produto do crime, evidente, para o Ministério Público, a finalidade comercial da conduta e entrega a consumo de terceiros.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 152-154, seguindo-se a regular citação às fls. 197, 198 e 199, com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 166-172).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado os réus. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 322-331). A Defesa requereu o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante por considerar ilegal a invasão do imóvel pelos policiais. No mérito, requereu a absolvição de MARCELO e DERICK por ausência de provas. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão de MARCOS e os bons antecedentes de MARCELO e DERICK (fls. 335-352).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Há alegação de nulidade que precisa ser apreciada antes do mérito. Passo à análise.

2.1 Sobre a (ir)regularidade da prisão em flagrante e do ingresso na residência

A Defesa sustenta que a prisão em flagrante dos réus é ilegal, assim como o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial.

A questão foi apreciada na audiência de custódia. Na oportunidade, se consignou:

Não há se falar em ilegalidade do ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão tendo em vista que a diligência foi precedida de investigação apontando para a possível ocorrência do tráfico, com campanhas realizadas em dias alternados. No dia dos fatos, os policiais presenciaram ato característico de

tráfico, tendo visualizado MARCOS entregar algo a um possível usuário fora da residência e retornando para seu interior, como assinalado. A entrada no imóvel deu-se em ato contínuo a essa visualização.

Nesse contexto, tem-se presentes fundadas suspeitas que justificam o ingresso na residência haja vista se tratar de crime permanente (fls. 104).

O depoimento dos policiais no inquérito (fls. 03-04 e 05-06) dão conta, essencialmente, da existência de informações apontando a ocorrência do tráfico de entorpecentes da residência situada na Avenida Amazonas, 1433, na Vila Bela Vista, em Capão Bonito/SP.

A partir das informações recebidas, as testemunhas relatam terem realizado diligências preliminares e constatado a verossimilhança das informações recebidas pela Polícia Judiciária, haja vista terem visualizado, em dias e horários diversos, movimentação anormal de pessoas com características de usuários de entorpecentes. Pouco antes do ingresso na residência, de acordo com as testemunhas, os policiais estavam realizando campana e viram MARCOS entregando algo para um indivíduo em frente ao imóvel, retornando em seguida o seu interior. Apesar de tentarem abordar esse indivíduo, não tiveram êxito em conter a evasão e, conforme esclareceram em juízo, resolveram ingressar na residência para evitar que se livrassem dos entorpecentes eventualmente existentes no local.

Assim, considerando a existência de informações prévias indicando a ocorrência do tráfico, a realização de campanhas em mais de uma oportunidade com a visualização de movimentação atípica para o local, a observância, pelas testemunhas, de atos de comercialização em frente à residência, inclusive, momentos antes da abordagem policial, havia fundada suspeita da ocorrência de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente, vale ressaltar, que autorizavam o ingresso dos policiais na residência em questão, mesmo sem um mandado judicial.

Não há se falar, por conseguinte, em invasão de domicílio ou prisão ilegais.

No mais, presente as condições e não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo à análise do mérito.

2.2 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 19-22), auto de exibição/apreensão (fls. 23), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 24), fotos do material apreendido (fls. 66-67), laudo pericial (fls. 184-186), laudos periciais de exame químico-toxicológico positivos para maconha e cocaína, inclusive na forma de crack (fls. 226-229, 230-233 e 234-237) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu MARCOS, interrogado na fase policial, disse que: só se manifestará após conversar com seu advogado; a única coisa que deseja falar é que o irmão MARCELO e o amigo DERICK não tinham ciência de nada, pois estavam ali apenas para fumar um baseado (fls. 07)

Interrogado em juízo, disse que: confessa os fatos; MARCELO e DERICK não sabiam das demais drogas, apenas da maconha; chamou MARCELO e DERICK para fumarem; pegou o caroço para fracionar para fumarem devagar; estavam fumando e do nada viu um vulto na janela e os policiais apareceram armados; até brincou que nem era polícia; estava muito nervoso na hora pois os outros não sabiam das drogas; sentou no chão e foi algemado; depois acharam as outras drogas; os policiais disseram que "queria catar" o depoente e nada disseram sobre MARCELO e DERICK.

O réu MARCELO, interrogado em solo policial, disse que: é usuário de droga tipo maconha há muito tempo; realmente estava no cômodo onde foram encontradas as drogas; somente estava ali para fazer uso de um "baseado" com seu irmão e com um amigo de infância chamado "DERICK"; não tem conhecimento de que ali estava ocorrendo o tráfico; seu irmão o chamou para fumar um baseado e quando eu viu uma quantidade maior até indagou a ele, momento em ficou sabendo que ele iria viajar e, portanto, iria levar uma quantidade maior para seu consumo; não tem conhecimento de que havia outros tipos de drogas naquele cômodo; o cômodo em que foram encontrado

pertence ao seu irmão; não estava trabalhando no local, ou seja, "cortando" os entorpecentes; é usuário e trabalha registrado na estufa e não tinha conhecimento de que ali estava ocorrendo o comércio de drogas. (fls. 11-12)

Interrogado em juízo, disse que: nega os fatos; não sabe porque está sendo acusado; estava trabalhando e foi para casa para almoçar; o irmão o chamou para fumar um baseado pois tinha que voltar a trabalhar as 13 horas; do nada os policiais adentraram a residência; o trabalho do depoente é das 7 às 16 horas; no dia dos fatos faltou porque estava com muita dor de cabeça; tinha ido ajudar o irmão na firma dele, ao lado da residência; era registrado no seu emprego; não foi algemado; apenas MARCOS foi algemado; os policiais entraram perguntando por MARCOS; na hora estava calmo; MARCOS não estava acreditando que era a polícia; Silvio algemou MARCOS e o depoente pediu para ligar para a sua genitora; é usuário de maconha; quando os policiais entraram no quarto apenas MARCOS estava manuseando a droga; foi ajudar o irmão era umas 7 horas da manhã; era umas 11 e pouco foi almoçar; não tem outra entrada na residência sem ser pelo portão da frente.

O réu DERICK, interrogado em juízo, disse que: é usuário de droga tipo maconha desde os 18 anos; estava na casa dos irmãos MARCELO e MARCOS que são amigos de infância; estava ali para fazer uso de droga tipo maconha, pois é usuário dessa substância; não tem conhecimento se ali ocorre tráfico de drogas; confirma que estava no cômodo onde os policiais encontraram as drogas; na ocasião os irmãos também estavam presentes; gostaria de ressaltar que não estava ali para trabalhar ou seja, para "picar" os entorpecentes; não tem mais nada a dizer em sua defesa (fls. 15-16).

Interrogado em juízo, disse que: nega os fatos; não sabia que tinha toda aquela quantidade de drogas; só sabia da maconha porque iam fumar; foi às 9 horas da manhã na casa de MARCOS para fumarem maconha; a polícia invadiu às 11 horas; não viu os policiais encontrando as demais drogas; estava morando em Capão desde o dia 29/06; não foram algemados na hora da abordagem, apenas MARCOS; os policiais disseram que ele estava sendo investigado; o depoente e o MARCELO não foram algemados em momento algum; em momento algum saíram do quarto para entregar algo a pessoas na frente da residência; conhece MARCELO e MARCOS desde a infância e ia fumar na casa deles; ficou fora de Capão por 18 anos.

A testemunha, Silvio de Almeida Oliveira, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: é policial civil; na data em questão, estava em diligências pelo município de Capão Bonito com a finalidade de reprimir o crime de tráfico; há dias recebeu uma denúncia no sentido de que a pessoa alcunhada "Bigode" estaria comercializando drogas em sua residência; iniciou as campanas em dias e horários diversos; notou uma movimentação anormal de pessoas no local; tais pessoas tinham características de usuários de drogas; aproximou-se mais do local e visualizou o réu MARCOS entregando algo para uma pessoa no portão de sua residência; esperou o réu adentrar de volta para sua residência; foi abordar o suposto comprador que saiu correndo desenfreadamente; havendo fundadas razões que ali estava de fato ocorrendo o tráfico de drogas, até porque já tinham feito diligências preliminares em outros dias, decidiram por ingressar no imóvel; em um cômodo do local, encontrou os réus MARCOS, MARCELO e DERICK; de imediato já constatou a existência de grande quantidade de droga tipo maconha no chão, juntamente com uma faca, restando claro que eles estavam ali cortando as drogas para posterior venda; os réus foram então contidos e algemados, eis que havia risco de fuga; pediram apoio de outros policiais e com a chegada deles pode observar melhor o cômodo; encontrou 60 microtubos contendo cocaína em um armário e 23 pedras de "crack" que estavam embaixo de um sofá, havia certa quantia em dinheiro cuja origem não restou comprovada, celulares e embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes; apresentaram os investigados, objetos, valores e drogas ao plantão policial para as devidas providências de polícia judiciária (fls. 03).

Em juízo relatou que: havia informações por meio de denúncias anônimas e por meio de colaboradores que estranharam o fato de haver várias pessoas adentrando no local; passaram a monitorar o local à distância e verificaram que usuários de entorpecentes entravam no imóvel; no dia dos fatos, observaram que algumas pessoas ingressaram possivelmente para aquisição de entorpecentes; tentaram abordar um

indivíduo que chegou no local, porém ele conseguiu fugir; visualizaram que MARCOS ("Bigode") adentrou na residência, num cômodo que havia no fundo da residência; resolveram adentrar na casa e pegaram os três; MARCOS parecia estar fracionando os entorpecentes para venda; as porções de maconha estavam espalhadas pelo chão; solicitaram apoio pois "Bigode" queria sair do local e começou a fazer um tumulto; solicitaram reforço; diante do nervosismo dele, solicitaram o apoio; quando os três foram dominados encontraram embaixo do sofá outras 23 porções de crack embaladas e prontas para venda; encontraram em um uniforme da SPVIAS 60 pinos de cocaína prontos para venda; encontraram dinheiro e diversas embalagens vazias; o que compreendeu da situação era que os demais estavam participando da embalagem; no momento da abordagem estava apenas MARCOS manuseando os entorpecentes; os 3 estavam no quarto; já havia investigação em cima de DERICK por suposta venda de entorpecentes a uma indivíduo do PCC de SP; em relação ao MARCELO já tinham visualizado ele fazendo entrega a usuários na parte de fora da residência; já havia sido oferecida por outra equipe de investigação um relatório e um mandado de busca para a residência de MARCOS; para materializar a venda tem por objetivo prender também o usuário para caracterizar o tráfico; normalmente prendem o usuário a alguns metros da residência para não alertar o vendedor; o portão estava aberto; já haviam observado a venda diversas vezes; acredita que já tinham percebido a presença dos policiais; no cômodo onde foi encontrado os entorpecentes estavam apenas os três; na residência da frente, depois dos gritos de MARCOS apareceram familiares para tumultuar, dizendo que estavam sendo agredidos, mas nada disso aconteceu; DERECK e MARCELO estavam a menos de um metro de MARCOS; a pessoa que foi comprar entorpecentes antes entrou no cômodo em que os réus estavam; notaram MARCELO fazendo a venda em frente à residência em outros dias; ele escondia as drogas embaixo de uma telha; no dia da prisão viram apenas MARCOS realizando a venda.

A testemunha, Alessandro Corbage de Sá, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: é policial civil; na data em questão, juntamente com seu colega desserviço Silvio, estava em diligências pelo município de Capão Bonito com a finalidade de reprimir o crime de tráfico; há dias recebeu uma denúncia no sentido de que a pessoa alcunhada "Bigode" estaria comercializando drogas em sua residência; iniciou-se as campanhas em dias e horários diversos; notou uma movimentação anormal de pessoas no local; tais pessoas tinham características de usuários de drogas; aproximou-se mais do local e visualizou o réu MARCOS entregando algo para uma pessoa no portão de sua residência; esperou o réu adentrar de volta para sua residência; foi abordar o suposto comprador que saiu correndo desenfreadamente; havendo fundadas razões que ali estava de fato ocorrendo o tráfico de drogas, até porque já tinham feito diligências preliminares em outros dias, decidiram por ingressar no imóvel; em um cômodo do local, encontrou os réus MARCOS, MARCELO e DERICK; de imediato já constatou a existência de grande quantidade de droga tipo maconha no chão, juntamente com uma faca, restando claro que eles estavam ali cortando as drogas para posterior venda; os réus foram então contidos e algemados, eis que havia risco de fuga; pediram apoio de outros policiais e com a chegada deles pode observar melhor o cômodo; encontrou 60 microtubos contendo cocaína em um armário e 23 pedras de "crack" que estavam embaixo de um sofá, havia certa quantia em dinheiro cuja origem não restou comprovada, celulares e embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes; apresentaram os investigados, objetos, valores e drogas ao plantão policial para as devidas providências de polícia judiciária. (fls. 05). Em juízo relatou que: chegou ao conhecimento do depoente e seu parceiro que estaria havendo traficância no local até por moradores da região mesmo; outros policiais também receberam as denúncias acerca do tráfico; preliminarmente começaram a campear o local para checar as informações; constataram que realmente estava havendo a traficância; havia uma movimentação intensa, incomum, fora e dentro da residência, ora pelo MARCOS, ora pelo MARCELO; outra equipe de investigação havia fechado questão quanto a isso e solicitaram mandado de busca e apreensão; no dia dos fatos visualizaram a entrada e saída do usuário e decidiram abordá-lo; porém não conseguiram prendê-lo; MARCOS foi até os fundos da residência e resolveram

adentrar para evitar que se livrassem dos entorpecentes; encontraram drogas pelo chão; MARCOS começou a criar tumulto; precisaram chamar reforços; quando chegou apoio, encontraram mais entorpecentes, dinheiro; quando adentrou no local acreditava que seria apenas MARCOS pois no dia não tinha visto os outros dois réus; o depoente já estava de campana havia algum tempo, o que significa que eles já estavam lá há algum tempo; no dia dos fatos não viu MARCELO ou DERICK vendendo drogas; quando chegou no cômodo, no exato momento em que adentrou, MARCELO e DERICK não estava manuseando drogas; quando MARCOS começou a gritar chegaram os familiares e fizeram tumulto; não conseguiram abordar um comprador; no dia dos fatos chegaram no local por volta das 10 horas da manhã.

A informante da Defesa, Nhagela Micaele Marques, ouvida em juízo disse que: é prima de DERICK e amiga de MARCOS e MARCELO; ficou sabendo que havia alguém armado na casa de MARCOS e MARCELO e resolveu ir até o local; chegando lá encontrou o policial Silvío, o qual disse que tinham um mandado judicial; sabia que os réus eram usuários, porém não traficantes; DERICK se mudou há pouco tempo e estava morando inclusive na casa da depoente.

Daniela Alves Brito, ouvida como informante, disse que: no dia dos fatos, um pouco antes da polícia invadir o local, a depoente tinha ido procurar a mãe de MARCELO e MARCOS e ela não estava; saiu e logo voltou e a polícia já estava lá; ficou apavorada e foi avisar Douglas e Nhagela Micaele já sabia que DERICK estava lá; quando estava lá só chegou até a lavanderia, nunca vai até o fundo; sabe que os réus são usuários de drogas, porém nunca suspeitou de venda.

Celia Santos da Silva França, mãe de MARCELO e MARCOS, ouvida como informante, disse que: no momento da prisão não estava na residência; Daniela ligou avisando outro filho da depoente que tem uma oficina próxima da residência; o filho ligou para a depoente avisando sobre o acontecido; quando chegou deu de cara com um rapaz com um boné, calça jeans e camiseta preta e achou que era um bandido; a pessoa de identificou como policial e começou a fazer a abordagem; não foi permitida entrar no local e entrou em pânico; depois chegaram outros policiais; a depoente mora na frente; no fundo tem dois cômodos e o MARCOS fica em um deles, no local em que foi abordado; no segundo cômodo moram MARCELO e a esposa; não sabia que havia venda de drogas na residência; MARCOS estava procurando serviço; se a depoente soubesse não permitiria.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a

indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório, tem-se que apenas o réu MARCOS admitiu a propriedade dos entorpecentes, isentando MARCELO e DERICK.

Com efeito, MARCELO e DERICK mantiveram em juízo a mesma versão apresentada na Delegacia. Não há inconsistências significativas nos relatos de ambos. Os dois indicam que foram até o local para consumirem maconha com MARCOS. Embora tenham sido presos no mesmo local em que as drogas foram encontradas, ambos negaram qualquer ciência da presença dos demais entorpecentes e MARCOS, igualmente, desde seu depoimento perante a Autoridade Policial, vem afirmando que os demais réus nenhuma relação possuem com os entorpecentes.

É certo que a testemunha Silvio menciona ter visto MARCELO entregar algo a supostos usuários em outras oportunidades e que DERICK teria comercializado entorpecentes com um traficante ligado ao PCC. Contudo, apesar da fé pública da testemunha policial e da ausência de motivos para incriminar falsamente os réus, essa circunstância não é suficiente para implicar MARCELO e DERICK.

Quando os policiais ingressaram na residência, apenas MARCOS manuseava o entorpecente. As denúncias recebidas pelos policiais acerca da ocorrência de tráfico no local não indicaram os nomes de MARCELO e DERICK.

Nessa contextura, ainda que estivessem no cômodo utilizado por MARCOS na ocasião da prisão, não há nos autos evidência robusta o suficiente para afastar as alegações de ambos, no sentido de terem ido até o local apenas para o consumo conjunto de maconha.

Portanto, por ausência de provas suficientes para a condenação, os réus MARCELO e DERICK devem ser absolvidos. Não há como imputar a eles a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Quanto a MARCOS, por outro lado, tem-se que ele admitiu a propriedade dos entorpecentes e, pouco antes da entrada dos policiais e de sua prisão foi visualizado entregando o que muito provavelmente era entorpecente a um usuário em frente à residência.

Os depoimentos das testemunhas Silvio e Alexandre dão conta de que MARCOS era constantemente visto em atitude semelhante (de entrega de algo a usuários que chegavam na residência) e que a frequência de pessoas no local era deveras suspeita.

No cômodo utilizado por MARCOS, devidamente separado da outra residência existente no mesmo terreno, os policiais encontraram maconha, crack e cocaína, além de anotações compatíveis com a contabilidade da traficância e sacos plásticos comumente utilizados para a embalagem de entorpecentes.

Portanto, no que tange a MARCOS, há provas suficientes de autoria e materialidade do delito a justificarem a necessidade de responsabilização penal.

O réu, de forma consciente e espontânea, guardava e mantinha em depósito drogas para fins de tráfico, consistentes em 13 porções de maconha com massa bruta total de 14,29 gramas; 13 porções de crack com massa bruta total de 3,88 gramas; e 60 pinos de cocaína com massa bruta total de 41,59 gramas. Conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata dos art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Com isso, está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitivas e volitivas, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de suas condutas e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisessem de outra forma. Optou

pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu MARCOS VINICIUS SANTOS FRANÇA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

2.3 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.3.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida maconha, cocaína e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 13 porções de maconha com massa bruta total de 14,29 gramas; 13 porções de crack com massa bruta total de 3,88 gramas; e 60 pinos de cocaína com massa bruta total de 41,59 gramas. O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.).

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceu duas circunstâncias como negativa (a natureza e a qualidade da droga), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se constar a circunstância da reincidência (cf. fls. 287-288, autos nº. 6-39.2020, 1ª Vara de Conchas/SP, com trânsito em julgado em 05/10/2021), razão pela qual agravo a pena 1/6, tornando a pena provisória em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, considerando a reincidência do réu, incabível a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Ausentes causas de aumento, torno definitiva a pena em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa.

2.3.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer

que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo para condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão) o fato de MARCOS ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2.3.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso, o réu MARCOS foi condenado a pena superior a 4 anos e, portanto, não satisfaz o requisito objetivo para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), nem para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

2.3.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.3.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receiptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a

análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal:

a) CONDENAR o réu MARCOS VINICIUS SANTOS FRANÇA pela prática do delito previsto no art. art. 33, caput, Lei nº 11.343/06 às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 816 dias-multa;

b) ABSOLVER os réus MARCELO SILVA FRANÇA e DERICK LUCAS MARQUES MENDES da acusação de prática do delito previsto no art. art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, c.c o art. 29, do Código Penal com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

FIXO o valor do dia-multa para o réu MARCOS em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu MARCELO, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva do réu MARCOS por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, já que demonstrou clara tendência à prática criminosa por ser reincidente, o que representa risco à ordem pública, e não constam informações acerca do endereço e trabalho, de modo ser necessária à garantia de cumprimento da lei penal.

Recomende-se a manutenção da custódia cautelar. Expeça-se a guia de recolhimento provisório.

REVOGO a prisão preventiva dos réus MARCELO e DERICK em decorrência da absolvição. Expeçam-se os alvarás de soltura clausulados.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos às fls. 23 por ser produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA